

**THALES FLORES
TAIPINA**

Manual da **SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA**

Teoria e Prática

7ª edição

Revista, atualizada e ampliada

2025

 **EDITORA**
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

O CONTEÚDO DECISÓRIO DO DISPOSITIVO E AS PROVIDÊNCIAS FINAIS

Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho; para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo

Lucas, 12; 58-59

1. CONTEÚDO DECISÓRIO

Como salientado, o dispositivo da sentença não se restringe a abrigar o processo dosimétrico da pena privativa de liberdade e da pena de multa. Ao contrário, compreende todo o conteúdo decisório da sentença, de modo que, o que nele estiver inserido, será alcançado pela coisa julgada.

Nesse passo, cabe mais uma vez reiterar que a determinação da pena final decorrente da aplicação de alguma das três espécies de concurso de crimes não faz parte do processo de dosagem da pena, sendo externo a este, não obstante o seu evidente conteúdo decisório.

Em semelhantes termos, afirma-se, então, que todas as decisões decorrentes da condenação penal fazem parte do dispositivo da sentença, razão pela qual deve este ser organizado em tópicos referentes aos temas específicos que decorrem necessariamente da condenação penal.

Assim, fazem parte do dispositivo da sentença: a) a estipulação da medida de segurança ao semi-imputável; b) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; c) a possibilidade de se detrair da pena fixada o tempo de prisão, provisória ou administrativa com o exclusivo fim de se adequar ao regime inicial de cumprimento da pena; d) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e) a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena; f) a decisão que mantém a prisão cautelar, que a decreta ou que a revoga; g) a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração; h) e a determinação quanto aos efeitos específicos da condenação penal.

1.1. Substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança decorre das situações em que se verifica a semi-imputabilidade do réu. Neste caso, como vimos no tópico 3.8.2.3, caberá ao Magistrado, na terceira e última etapa do processo dosimétrico e com amparo no artigo 26, Súnico, do Código Penal, minorar a pena encontrada em sua fase intermediária, alcançando, então a pena definitiva, caso não haja concorrência de circunstâncias majorantes.

Assim, determinada a pena final, reduzida em razão da semi-imputabilidade, e sendo o caso de substituí-la por medida de segurança, tal providência precederá à fixação do regime prisional preambular, que restará prejudicado, por absoluta desnecessidade.

Pois bem. A substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança é determinada pelo artigo 98 do Código Penal, nos seguintes termos: “na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade **pode** ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§1º a 4º”

Como se extrai da redação do dispositivo em tela, nem sempre a pena aplicada ao semi-imputável será substituída por medida de segurança, mas tão somente nas hipóteses em que este necessitar de **especial tratamento curativo**. Neste caso, poderá o Juiz substituir a pena aplicada pela internação ou por tratamento ambulatorial.

Observa-se, em primeiro plano, que a utilização do verbo ‘poder’ não significa uma faculdade conferida ao Magistrado para optar entre o cumprimento da pena privativa de liberdade ou submeter o sentenciado à medida de segurança. Isso porque, diagnosticada a necessidade de tratamento especial para o alcance da cura, a substituição torna-se ato vinculado, escapando à discricionariedade do Julgador. Como salienta Galvão, “havendo possibilidade de tratamento para

o indivíduo psiquicamente incapacitado, não é concebível que o juiz negue-lhe acesso a esse tratamento.”¹

Destaca-se, em segundo plano, que a medida de segurança a ser aplicada também configura ato vinculado do Magistrado, haja vista que a **internação**, consoante os termos do artigo 97 do CP, foi imposta pelo legislador como medida detentiva para **fatos puníveis com reclusão**, enquanto o **tratamento ambulatorial** foi reservado, como medida restritiva, ao semi-imputável autor de **fato punível com detenção**. Veja-se:

Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível **com detenção**, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

No entanto, impõe-se destacar que as medidas de segurança devem ser aplicadas em observância a determinadas garantias que se amparam no princípio maior da dignidade humana, entre os quais, sublinhe-se a **proporcionalidade** da medida à **periculosidade** do sujeito reconhecidamente semi-imputável.

Assim, malgrado a dicção legal, a medida de segurança, de internação ou tratamento ambulatorial, diante do princípio da dignidade humana, não cabe ser graduada em proporção à espécie de pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção, mas consoante o grau da incapacidade mental diagnosticado e dos meios necessários à recuperação do semi-imputável.

Sobre o tema, salienta ainda Galvão que a Lei 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental, revogou a regra de que a espécie de medida de segurança deve ser graduada em conformidade com a espécie de pena privativa de liberdade prevista para a conduta realizada.²

Isso porque, em seu artigo 4º, estabeleceu o legislador a internação como **medida subsidiária**, ou seja, “quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”³ Parte-se, portanto, de uma ideia de **suficiência** de recursos extra-hospitalares e, em última instância, de **necessidade** da medida mais gravosa, que é a internação em manicômios judiciários.

Portanto, ao aplicar a medida de segurança ao semi-imputável, deverá o Juiz pautar sua decisão conforme a conclusão exarada no laudo pertinente ao exame de integridade mental no tocante ao tratamento adequado à patologia diagnosticada, não devendo se ater à espécie de pena privativa de liberdade prevista para o fato. Em outros termos, o Juiz não está obrigado a determinar a internação em face apenas da previsão de reclusão para a punição do crime praticado, haja vista

1. GALVÃO, Fernando. *Direito Penal: Parte Geral*. 10ª edição. Ed. D'Plácido, p. 998.

2. *Idem*, p. 994.

3. Lei 10.216/2001. Art. 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

a possível suficiência dos tratamentos extra-hospitalares para a recuperação do sentenciado.

1.1.1. *Desnecessidade de realização do processo dosimétrico*

Questão que surge interessante diz respeito à necessidade de ser dosimetrada a pena privativa de liberdade para fins de sua substituição por medida de segurança. Em outros termos, questiona-se:

Sendo o caso de substituição da pena por medida de segurança, é necessária a realização do processo dosimétrico e determinação do valor da pena privativa de liberdade?

Parece-me unânime em doutrina que sim.

Fernando Galvão, por exemplo, afirma que “nesse caso (de substituição), **a decisão ainda será condenatória, pois é necessário primeiro aplicar a pena para depois substituí-la**, e a medida de segurança a ser imposta em nada difere da que é aplicada aos inimputáveis.”⁴ (grifei)

Rogério Greco, por sua vez, salienta que “as colocações que devem ser feitas são as seguintes: o semi-imputável foi condenado; **foi-lhe aplicada uma pena**; agora, em virtude da necessidade de especial tratamento curativo, pois sua saúde mental encontra-se perturbada, a pena privativa de liberdade a ele **aplicada** poderá ser substituída pela internação ou pelo tratamento ambulatorial.”⁵(grifei)

Cita-se, ainda, Paulo César Busato, para quem “nesta hipótese, justamente porque se trata de substituição, **deverá o juiz primeiramente aplicar a pena**, para depois substituí-la.”⁶(grifei)

Pois bem. Não obstante o peso jurídico das opiniões manifestadas, com elas não concordo, com a máxima vênia, por crer que a realização do processo dosimétrico não tem a menor necessidade prática. Explico.

Como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança somente terá cabimento em relação ao semi-imputável **que necessitar de especial tratamento curativo**. Não sendo o caso, o processo dosimétrico deverá ser realizado e estabelecida a quantidade da pena privativa de liberdade, o regime prisional preambular e todo o mais necessário ao seu integral cumprimento.

Demais disso, a substituição em tela não se cuida de faculdade do Juiz, como registrado. Logo, constando do laudo pericial, já integrado aos autos quando da fase da sentença, que o réu necessita, para fins curativos, de especial tratamento,

4. GALVÃO, Fernando. *Direito Penal: Parte Geral*. 10ª edição. Ed. D'Plácido, p. 997.

5. GRECO, Rogério. *Código Penal Comentado*. 13ª edição. Ed. Ímpetus, p. 325.

6. BUSATO, Paulo César. *Direito Penal: Parte Geral*. 4ª edição. Ed. Atlas, p. 836. O autor afirma que no mesmo sentido é a posição de César Roberto Bitencourt.

pergunta-se: qual a necessidade de se dosar a pena privativa de liberdade diante da obrigação imposta ao Magistrado de substituí-la por medida de segurança?

Perceba-se que a rubrica do artigo 98 do CP fala em “**Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável**”, deixando claro que a substituição se refere à privação da liberdade como espécie de pena (art. 32, I, CP), haja vista que **a pena será substituída, independentemente do total dosimetrado**. Veja-se que, ao redigir o dispositivo, o legislador foi expresso ao estabelecer que “*a pena privativa de liberdade pode ser substituída...*”.

Ademais, nota-se que o legislador faz referência expressa às espécies de medidas de segurança em conformidade com a **espécie de pena privativa de liberdade** prevista para a conduta penal realizada, **reclusão** ou **detenção** (art. 97, CP), sem nenhuma vinculação com o total da pena a ser aplicada.

Observa-se, nesse ponto, que não obstante a citada disposição legal, o STJ entendeu que “**não deve ser considerada a natureza** (diga-se, a espécie) **da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.**”⁷ Cuida-se de compreensão que corrobora o entendimento ora exposto, haja vista que a quantidade da pena não é determinante à avaliação do grau de periculosidade do réu, assim como a natureza (ou espécie) da pena cominada ao crime não importa à determinação da medida de segurança adequada ao restabelecimento da integridade mental do acusado.

Dessa maneira, deduz-se que imprescindível é a **condenação**, ou melhor, a **decisão condenatória**, com a submissão do sentenciado aos preceitos de determinado tipo penal incriminador para o qual haja previsão de pena privativa de liberdade. O total da pena não tem a menor importância, nem mesmo para estabelecimento do prazo mínimo da medida de segurança, que é determinado legalmente, entre 01 a 03 anos (art. 97, §1º, CP).

Poder-se-ia argumentar que o total da pena aplicada tenha importância para a determinação do **tempo máximo** de vigência da medida de segurança. No entanto, semelhante argumento não procede. *Primeiro*, porque uma coisa são os pressupostos legitimadores da substituição, outra, bem diferente, é o tempo de duração da medida de segurança substitutiva, que será indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade (CP, art. 97, §1º). *Segundo*, porque a Súmula 527 do STJ estabelece que “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena **abstratamente** cominada para o delito praticado.”

Nesse sentido, decidiu o TJRS:

7. STJ - EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 18/12/2019

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. **A medida de segurança poderá perdurar enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade do agente, observado, contudo, o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito imputado ao réu, conforme a Súmula n.º 527 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.**⁸

Observa-se, portanto, que também em relação ao tempo máximo de vigência da medida de segurança, seja a internação, seja o tratamento ambulatorial, o STJ não destinou a menor relevância ao total da pena aplicada.

Afirma-se ainda, que uma vez constatada a cessação da periculosidade do sentenciado (art. 97, §1º, do CP e art. 175, LEP), independente do tempo realizado da medida de segurança, restará extinta a punibilidade, o que confirma a desnecessidade de quantificação da pena privativa de liberdade substituída, haja vista a impossibilidade de ser o sentenciado submetido ao cumprimento do tempo remanescente da pena (eventualmente) aplicada diante da abolição do sistema do Duplo Binário.⁹

Como decidido pelo STJ, “o sistema vicariante afastou a imposição cumulativa ou sucessiva de pena e medida de segurança, uma vez que a aplicação conjunta ofenderia o princípio do *ne bis in idem*, já que o mesmo indivíduo suportaria duas consequências em razão do mesmo fato.”¹⁰

Sublinhe-se, como derradeiro argumento, que para a substituição da pena privativa de liberdade **por pena restritiva de direitos**, a realização do processo dosimétrico é **imprescindível**, uma vez que o legislador condicionou a concessão desse benefício ao tempo de pena aplicada, é dizer, apenas aos condenados a sanções **não superiores a 04 anos de prisão**, conforme artigo 44, I, CP. Como se constata, semelhante requisito não foi exigido para a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, pois que fundamentada na periculosidade do sujeito, não na reprovabilidade do fato.

Em conclusão, afirma-se que diante da necessidade de especial tratamento curativo ao semi-imputável, aferida pelo exame de integridade mental, a pena privativa de liberdade deverá ser substituída por medida de segurança, **independentemente da sua quantidade**, razão pela qual, em minha compreensão, a realização do processo de dosagem da reprimenda se afigura absolutamente **desnecessária**.

8. TJRS - AGV: 70080810211 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019

9. O sistema do Duplo Binário ou de Dois Trilhos, vigente na Parte Geral do Código Penal de 1940, permitia a aplicação simultânea de pena privativa de liberdade e medida de segurança. Com a sua reforma em 1984, tal critério deu lugar ao Sistema Vicariante, permitindo-se a aplicação da pena somente ao indivíduo imputável e a medida de segurança os inimputáveis.

10. STJ - HC n. 275.635/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016.

1.2. Fixação do regime prisional preambular

Considerando a doutrina majoritária, da qual divirjo, a realização do processo dosimétrico é necessária mesmo diante da obrigatoriedade de substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança. Neste caso, como afirmado, resta prejudicada a necessidade de fixação do regime prisional preambular, pois, com a submissão do sentenciado à medida de segurança, não há mais que se falar em cumprimento de pena privativa de liberdade em virtude da adoção do Sistema Vicariante pela reforma da Parte Geral do Código Penal em 1984.

Lado outro, não sendo o caso de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, a fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda corporal será a primeira providência que se seguirá à dosagem da pena.

Registra-se, então, que para a determinação do regime prisional preambular, deverá o Julgador observar cinco pressupostos, que são os seguintes:

1. A espécie (ou natureza) da pena privativa de liberdade prevista para o crime julgado, se reclusão ou detenção;
2. A quantidade da pena aplicada ao réu;
3. Se o sentenciado é reincidente ou primário;
4. As circunstâncias judiciais valoradas para a fixação da pena-base.
5. A detração penal, devendo ser computado no tempo da pena aplicada o período em que o sentenciado tenha ficado preso cautelarmente.

Vejam, então, cada um desses pressupostos.

1.2.1. Gradação do regime prisional conforme a espécie da pena privativa de liberdade

Cabe destacar, conforme os preceitos do “caput” do referido artigo 33 do CP, que a imposição do regime fechado não se afigura possível para crimes punidos com detenção, independente da quantidade da pena fixada, da verificação da reincidência ou mesmo da valoração negativa de uma, algumas ou de todas as circunstâncias judiciais. Confira-se:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Também nessa situação vislumbra-se a opção do legislador, pautado pela valoração axiológica do bem jurídico realizada na fase **legislativa** da individualização da pena, de destinar o regime de inteira clausura apenas aos crimes punidos com reclusão.

Em outros termos, afirma-se que, por opção do legislador penal, em caso de crime punido com **detenção**, poderá ser fixado o regime semiaberto ou o regime aberto, porém, jamais o regime fechado. Assim, enquanto para os crimes punidos com **reclusão** se afigura possível a fixação de qualquer dos três regimes prisionais, fechado, semiaberto ou aberto, naqueles punidos com **detenção** somente será legítima a fixação dos regimes semiaberto ou aberto.

Observa-se que, em caso de concurso de crimes punidos com reclusão e detenção, deve o Magistrado sentenciante fixar os regimes específicos conforme a espécie de pena prevista para cada crime. Assim o fazendo, a execução das penas será cumprida na forma do artigo 69, *caput*, parte final, do Código Penal, segundo o qual, “**no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.**” No mesmo sentido o artigo 681 do Código de Processo Penal: “**Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples.**”

Portanto, à vista de semelhante situação, é vedado ao Magistrado sentenciante a aplicação dos critérios do cúmulo material e da exasperação das penas para a definição do regime prisional preambular.

Nota-se, ademais, como destaca a parte final do dispositivo em tela, a necessidade de transferência a regime fechado. Neste caso, porém, cuida-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, determinada pelas hipóteses de **soma ou unificação das penas e regressão de regime**, conforme disposições dos artigos 111 e 118, da Lei 7.210/84, respectivamente.

Conclui-se, portanto, que o primeiro fator a ser considerado para a fixação do regime prisional preambular, em qualquer situação, é a **espécie da pena privativa de liberdade eleita pelo legislador** para o crime sob julgamento, **reclusão** ou **detenção**.

1.2.2. Gradação do regime prisional conforme a quantidade da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais

Consoante a dicção legal do artigo 33, ‘*caput*’ e §§2º e 3º, do CP, aferida a espécie da pena privativa de liberdade estabelecida pelo legislador ao crime sob julgamento, caberá ao Juiz sentenciante analisar os seguintes fatores para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) **quantidade da pena aplicada**; b) **reincidência**; c) **circunstâncias judiciais**.

Dessa forma, vista a espécie de pena privativa de liberdade prevista para o crime julgado, a análise da **quantidade da pena aplicada** será o passo seguinte para o Magistrado fixar o regime prisional em cujo ambiente o sentenciado iniciará o cumprimento da pena que lhe foi aplicada, haja vista que, a depender do valor da reprimenda, o regime prisional a ser fixado será **vinculado** ou **discrecional** ao Julgador.

Veja-se que, consoante as alíneas do §2º do citado dispositivo legal, sendo a pena aplicada **superior a 08 anos** de privação da liberdade, o regime inicial **deverá** ser o **fechado**, desde que se trate de crime punido com reclusão. Lado outro, se a pena for **superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito)**, **poderá** o Magistrado fixar o regime **semiaberto**. Por fim, caso a reprimenda seja **igual ou inferior a 4 (quatro) anos**, **poderá** o Juiz sentenciante determinar o regime **aberto**.

Confira-se:

Art. 33. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

- a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos **deverá** começar a cumpri-la em regime **fechado**;
- b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), **poderá**, desde o princípio, cumpri-la em regime **semiaberto**;
- c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, **poderá**, desde o início, cumpri-la em regime **aberto**.

Certifique-se, portanto, que diante de crimes punidos com reclusão, sendo a pena aplicada superior a 08 anos (alínea “a”), nenhuma outra consideração será necessária para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, que deverá ser obrigatoriamente o regime fechado (alínea ‘a’). Cuida-se, neste caso, de ato vinculado do Magistrado.

Destaca-se, ademais, que as disposições do §3º do mesmo artigo 33, segundo o qual “a **determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código**”, não exerce nenhuma influência nessa hipótese. Desse modo, ainda que o acusado seja primário e que todas as circunstâncias judiciais lhe sejam positivas, sendo a pena definitiva superior a 08 anos e o crime punido com reclusão, o regime prisional será sempre o mais severo.

Isso se justifica pelo **princípio da individualização legislativa da pena**, haja vista que o legislador fixou a necessidade de imposição do regime mais rigoroso unicamente em virtude da gravidade do crime, aferida pela valoração do bem jurídico tutelado, não deixando ao Magistrado nenhum parâmetro de discricionariedade.

Diferentes, no entanto, são as hipóteses estabelecidas pelas alíneas ‘b’ e ‘c’ do §2º transcrito, diante da discricionariedade conferida pelo legislador ao Magistrado para valorar a necessidade e suficiência do regime prisional preambular para o cumprimento da pena aplicada.

Nessas situações (alíneas ‘b’ e ‘c’ do §2º, art. 33, CP), a **reincidência** assume postura preponderante para a definição do regime prisional preambular. Isso porque, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam valoradas positivamente ao

sentenciado e ainda que a pena aplicada não seja superior a 08 anos, verificada a reincidência, caberá ao Magistrado, **necessariamente**, é dizer, por determinação legal, fixar o regime mais gravoso do que o permitir a pena imposta na sentença. Como reconheceu Busato, “não há outra maneira de proceder, dada a soberania do legislativo acerca da matéria.”¹¹

Assim, sendo a **pena fixada superior a 04 e não maior que 08 anos**, o regime prisional somente será o **semiaberto se o sentenciado não for reincidente**. O mesmo se afirma no tocante à **pena igual ou inferior a 04 anos**, situação em que o regime **aberto** somente será legítimo diante da primariedade do réu.

Vê-se, então, que as **circunstâncias judiciais** assumem sua postura de relevância no processo de fixação do regime prisional, conforme as disposições do §3º do artigo 33, e artigo 59, inciso III, ambos do CP, nas situações de penas fixadas abaixo de 08 anos de privação da liberdade (art. 33. §2º, alínea “a”) e, simultaneamente, quando o sentenciado não for reincidente (art. 33. §2º, alíneas “b” e “c”). Nesses casos, as circunstâncias judiciais é que determinarão o regime necessário e suficiente ao cumprimento inicial da pena imposta.

Nesse ambiente de valoração da suficiência e necessidade do regime prisional, necessário destacar a **Súmula 718 do STF**, cujo teor é o seguinte:

“A opinião do julgador sobre a **gravidade em abstrato** do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”¹²

Ressai, portanto, dos termos sumulados, que não cabe ao Juiz sentenciante valorar a gravidade do crime no plano puramente abstrato, é dizer, **desconsiderando-se as peculiaridades do caso concreto**, para concluir pelo mais adequado regime de cumprimento inicial da pena, uma vez que essa valoração abstrata já foi realizada pelo legislador ao estipular a correspondência dos regimes prisionais com as penas aplicadas, como se extrai do §2º do artigo 33, do CP.

Seguindo a mesma inteligência e esclarecendo ainda mais a questão, o STF editou a **Súmula 719**. Veja-se:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir **exige motivação idônea**.”¹³

Não resta dúvida, consoante o teor dos indigitados verbetes sumulares, que a ‘motivação idônea’ para a imposição de regime mais severo do que o permitir o valor da pena aplicada **deve ser pautada pela gravidade concreta do delito**, o que

11. BUSATO, Paulo César. *Direito Penal: Parte Geral*. 4ª edição. Ed. Atlas, pág. 915.

12. STF - Sessão Plenária de 24/09/2003- Publicação no DJ de 09/10/2003, p. 7; DJ de 10/10/2003, p. 7; DJ de 13/10/2003, p. 7

13. STF - Sessão Plenária de 24/09/2003- Publicação no DJ de 09/10/2003, p. 7; DJ de 10/10/2003, p. 7; DJ de 13/10/2003, p. 7.

somente caberá ser extraída (a gravidade concreta) **das circunstâncias judiciais** – culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e, inclusive, o comportamento da vítima.

Perceba-se que, com absoluta coerência, o STJ editou a **Súmula 440**, nos seguintes termos:

“Fixada a **pena-base no mínimo legal**, é **vedado** o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base **apenas na gravidade abstrata** do delito.”¹⁴

Significa afirmar que, se a pena-base foi fixada no mínimo legal, por óbvio todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente. Logo, não há gravidade em concreto que justifique a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena imposta ao final do processo dosimétrico. Se o Juiz o fizer, baseará sua decisão apenas em suas convicções pessoais quanto à gravidade abstrata do delito, o que lhe é defeso, por violação ao princípio da individualização legislativa da pena.

À vista do exposto, **pode ser questionado:**

Sendo a pena aplicada inferior a 04 anos e o réu primário, qual deve ser o regime prisional diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial?

1.2.3. Regime prisional per saltum

Vistos os pressupostos para a fixação do regime prisional preambular, merece destaque a divergência verificada na jurisprudência do STJ sobre qual regime prisional deve ser estabelecido na situação em que o sentenciado é reincidente, as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis e a pena é fixada em valor igual ou inferior a 04 anos. Será possível a aplicação, desde logo, do regime mais gravoso previsto, que é o regime fechado, ou deve ser considerado o regime imediatamente mais gravoso do que permitir a quantidade da pena aplicada?

Em outros termos:

Sendo o regime aberto correspondente ao montante da pena aplicada (não superior a 04 anos), a verificação da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem a fixação direta do regime fechado, ou deverá ser aplicado o regime semiaberto, por ser o imediatamente mais rigoroso que o regime aberto?

Observe-se, inicialmente, que se o crime for punido **com detenção**, **jamais poderá ser aplicado o regime fechado**, por força das disposições do “caput” do

14. STJ - Súmula 440, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010.

artigo 33 já transcrito. Logo, **a questão se estabelece diante da hipótese de crime punido com reclusão.**

Destaca-se que a Quinta Turma do STJ, em julgamento realizado em 07 de junho de 2018, manifestou-se pela possibilidade de se determinar desde logo o regime mais gravoso, *per saltum*, quando, não obstante a pena aplicada, o sentenciado for reincidente e a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais negativas. Segue-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. **PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE QUE TEVE VALORADA NEGATIVAMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.** AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite “a fixação de regime prisional **fechado** ao **réu reincidente**, condenado à pena inferior à 4 anos, **se a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal**” (AgRg no REsp 1.558.372/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2016). Agravo regimental desprovido.¹⁵

Nada obstante, a mesma Quinta Turma, em julgamento realizado em 12 de junho de 2018, portanto, apenas 05 dias após o precedente citado, manifestou entendimento diverso, preceituando, em essência, que a fixação do regime mais gravoso não pode ser determinado *per saltum*, é dizer, deve ser o regime imediatamente mais gravoso do que o determinado pela pena imposta. Confira-se:

Embora o quantum da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP) permita, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, bem como o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional **mais gravoso, que no caso é o semiaberto**, de acordo com o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Quinta Turma.¹⁶

No mesmo sentido da impossibilidade de fixação do regime prisional *per saltum*, salientou o TJDF:

A reincidência não leva necessariamente à fixação do regime fechado” (súmula 269). Para a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão o §2º do art. 33 do CP prevê regime inicial aberto. **A reincidência impõe o agravamento do regime para o imediato subsequente na gradação do dispositivo, qual seja, o regime semiaberto**, não se justificando o fechado.¹⁷

15. STJ - AgRg no REsp 1533819/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018.

16. STJ - HC 444.116/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

17. TJDF - APR: 201286220068070001 DF 0020128-62.2006.807.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 14/05/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/06/2009, DJ-e Pág. 290.

Em minha compreensão, porém, a fixação do regime mais rigoroso, *per saltum*, não encontra óbice legal diante da necessidade de ser avaliada, conjuntamente, a reincidência e as circunstâncias judiciais, desde que pautado em fundamentação idônea. Aliás, nesses termos, estabelece a mesma Súmula 269 do STJ, veja-se:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”¹⁸

A interpretação a *contrarium sensum* da súmula em destaque conduz à lógica conclusão de que, aplicada pena igual ou inferior a 04 anos de privação da liberdade, sendo o réu reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, poderá o Juiz desde logo fixar o regime fechado..

Em outros termos, ainda que a pena aplicada permita a fixação do regime aberto, a verificação da reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais autorizam a determinação imediata do regime prisional fechado, não sendo obrigado o Magistrado à mesma gradação conferida pelo legislador no artigo 33, §2º, do CP.

Confira-se o mais recente posicionamento do STF a respeito do tema:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.

1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 3. “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, **a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação**” (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017).¹⁹

Semelhante entendimento manifestou o STJ ao decidir que uma vez “fixada a quantidade da sanção devida a quem, comprovadamente, violou a norma penal, compete ao juízo natural da causa indicar, de maneira motivada e com base nos dados concretos dos autos, qual o regime inicial adequado para o cumprimento

18. STJ - Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135.

19. STF - HC 142602 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017.

da reprimenda, **não sendo possível coarctar-lhe a consideração de fatores que, associados e complementares à dogmática penal, indiquem como necessária, para o alcance dos fins da pena, a imposição de regime mais gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal.**²⁰

Por derradeiro, importa registrar que a valoração das circunstâncias judiciais para fins de determinação do regime prisional preambular deve ser feita de forma **qualitativa e não quantitativa**. Compreende-se, pois, que a imposição do regime prisional mais gravoso não requer a desaprovação integral ou majoritária das circunstâncias judiciais destacadas pelo artigo 59 do Código Penal, **“podendo existir uma só circunstância que, por sua intensidade, faça pesar a balança em um sentido ou em outro.”**²¹

Percebe-se, pois, também para a fixação do regime prisional preambular, o critério da proporcionalidade axiológica para a valoração das circunstâncias judiciais.

1.2.4. Detração penal

Como visto linhas atrás, o legislador penal determinou o regime inicial de cumprimento da pena, prioritariamente, a partir da gravidade da reprimenda imposta ao final do processo dosimétrico, ou seja, tendo em vista um critério de razoabilidade entre a gravidade da pena imposta e o regime necessário para o alcance das finalidades da pena.

Nesse viés, considerando a necessidade da prisão cautelar em determinados casos e, ainda, as dificuldades amiúde verificadas para o efetivo cumprimento do princípio da razoável duração dos processos, a Lei 12.736/2012 incluiu o §2º ao artigo 387 do CPP para determinar ao Juiz sentenciante considerar o tempo de segregação provisória cumprido pelo sentenciado a fim de se estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena. Confira-se:

Art. 387. (...) § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado **para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade**.

Destaca-se, em vista da disposição legal transcrita, que a detração do tempo de prisão cautelar, carcerária ou domiciliar, somente será necessária quando, ao se subtrair da pena aplicada o tempo cumprido da prisão provisória, a pena correspondente ao resultado da operação determinar a alteração do regime prisional preambular, conforme as disposições do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Ilustrando, sendo a pena imposta de **08 anos e 06 meses**, o regime prisional seria o **fechado**, em razão das disposições do artigo 33, §2º, ‘a’ do Código Penal.

20. STJ - HC 328.956/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016.

21. BUSATO, Paulo César. *Direito Penal: Parte Geral*. 4ª edição. Ed. Atlas, pág. 916.

Considerando, porém, o período de prisão cautelar de **08 meses**, com a detração, o tempo remanescente de cumprimento da pena imposta será de **07 anos e 10 meses**. Logo, deverá ser aplicado o regime **semiaberto**, nos termos do artigo 33, §2º, 'b', do CP.

Observa-se, entretanto, que a detração do tempo de prisão, provisória ou administrativa (ou o de internação), não conduz, por si só, à automática fixação do regime prisional mais brando, correspondente à pena dosada.

Assim, ainda que a detração do tempo de prisão provisória permita a fixação do regime prisional preambular menos severo em razão do valor remanescente da pena a ser cumprida, o próprio artigo 33, §2º, do Código Penal impede a aplicação do benefício, em qualquer caso, diante da verificação da reincidência do sentenciado. Veja-se o STJ:

“Mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado.”²²

Todavia, uma questão que pode surgir é a seguinte:

É possível a detração da pena e a imposição do regime prisional mais brando ao sentenciado quando, não obstante primário, uma ou mais circunstâncias judiciais forem valoradas negativamente?

Observa-se que, a exemplo da reincidência, também a valoração negativa das circunstâncias judiciais poderá determinar a imposição de regime mais rigoroso. Nota-se que o art. 33, §3º do CP, estabelece que **“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código,”** que trata da valoração das circunstâncias judiciais para a dosimetria da pena-base. Por sua vez, o mesmo o artigo 59, inc. II, determina a valoração das circunstâncias judiciais para definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Percebe-se, então, que não é apenas a quantidade da pena, computada após a detração do tempo de prisão provisória ou administrativa, que determina a alteração do regime prisional preambular, até porque o artigo 387, §2º, do CPP, não faz essa exigência. É necessário ainda aferir se o regime mais gravoso foi ou não justificado pela reincidência ou mesmo pela valoração negativa das circunstâncias judiciais. Observa-se, nesses termos, os recentes precedentes do STJ, por suas Quinta e Sexta Turmas. Seguem-se:

22. STJ - AgRg no AREsp n. 2.037.116/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022

A detração do tempo de prisão cautelar não resultaria na modificação do regime inicial de pena, já que **a presença de circunstância judicial negativa, por si só, justifica a fixação do regime inicial imposto.**²³

A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que **a existência de circunstância judicial negativa, como maus antecedentes, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão.**²⁴

Não há dúvida, portanto, que a valoração negativa das circunstâncias judiciais pode impedir o abrandamento do regime prisional preambular, não obstante a permissão pelo valor da pena aferida em razão da detração do tempo de prisão no curso do processo.

Sem embargo, duas observações parecem-me necessárias.

A primeira, é que a valoração das circunstâncias judiciais para a determinação do regime prisional preambular não deve ser apenas quantitativa, mas, inclusive, **qualitativa**, ou seja, axiológica, valorando-se o grau de intensidade da circunstância na reprovabilidade da conduta e do seu autor.

Diante de tal premissa, diga-se, da valoração qualitativa, surge a segunda observação, qual seja, a valoração negativa de **apenas uma** circunstância judicial **pode impedir ou não** o regime prisional mais brando em razão da detração do tempo de prisão provisória. Nesses termos, é possível que no caso em julgamento a culpabilidade seja extremamente reprovável, de modo que impeça o regime menos rigoroso que o possibilitado pelo saldo da pena. Mas é possível também que o sentenciado seja possuidor de apenas um título condenatório característico de maus antecedentes, ainda assim, em decorrência do efeito depurador (CP, art. 64, I), sendo, portanto, tecnicamente primário.

Dessa forma, compreendo ser fundamental que o Juiz sentenciante busque sempre valorar o grau de reprovabilidade das circunstâncias judiciais negativas no caso em julgamento, a fim de definir o mais adequado regime prisional ao sentenciado à vista das finalidades retributiva e preventiva da pena. (CP, art. 59).

É possível, pois, compreender que o §3º do artigo 33 do CP não impõe ao Magistrado uma vinculação, como o fez o legislador no tocante à reincidência (§2º, art. 33), porém, uma **recomendação**, uma vez que, por força do artigo 59, *caput*, e inc. III, do CP, a fixação do regime prisional preambular também deve se orientar pelas finalidades da pena.

Desse modo, em relação ao sentenciado primário que, por exemplo, tenha contra si um título condenatório característico de maus antecedentes em decorrência do efeito depurador (CP, art. 64, I), fixada a pena em 07 (sete) anos e 10

23. STJ - REsp n. 2.186.128/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.

24. STJ - REsp n. 2.071.199/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.